

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

A R R E S T

**nr. 179.864 van 19 februari 2008
in de zaak A. 186.895/XII-5328.**

In zake : de NV HOUBEN,
die woonplaats kiest bij
advocaat J. Stijns,
kantoor houdende te Leuven,
Ubicenter,
Philipssite 5

tegen :

de VZW ZUSTERHOF WOON- EN ZORGCENTRUM VOOR
OUDEREN,
die woonplaats kiest bij
advocaat C. De Wolf,
kantoor houdende te Maarkedal,
Etikhovestraat 6.

tussenkommende partij :

de NV HEIJMANS BOUW,
die woonplaats kiest bij
advocaat E. Empereur,
kantoor houdende te Berchem,
Uitbreidingstraat 2.

DE VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat de NV Houben op 2 februari 2008 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing te vorderen van

“- de beslissing dd. 22 januari 2008, poststempel met datum van 23 januari 2008, van de V.Z.W. ZUSTERHOF woon- en zorgcentrum om de opdracht ‘voor het bouwen van een rusthuis Hadschot Perceel algemene bouwwerken dossiernummer 7211 A’ niet aan de NV HOUBEN te gunnen;
- de impliciete beslissing van de V.Z.W. ZUSTERHOF woon- en zorgcentrum voor ouderen dd. 22 januari 2008, waarbij de voormelde opdracht aan de firma HEIJMANS BOUW NV, Taunusweg 49 te 3740 Bilzen wordt gegund”;

Gezien de nota en het administratief dossier van de verwerende partij;

Gelet op de beschikking van 5 februari 2008 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 14 februari 2008, om 10.30 uur;

Gezien het op 8 februari 2008 ingediende verzoekschrift waarbij de NV Heijmans Bouw vraagt in het administratief kort geding te mogen tussenkomen; dat zij voordeel blijkt te halen uit de bestreden beslissing en erbij belang heeft dat de vordering wordt afgewezen; dat haar verzoek dienvolgens moet worden ingewilligd;

Gehoord het verslag van kamervoorzitter D. Verbiest;

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. Verbeke, die loco advocaat J. Stijns verschijnt voor de verzoekende partij, van advocaat C. De Wolf, die verschijnt voor de verwerende partij, en van advocaat A. Verlinden, die verschijnt voor de tussenkomende partij;

Gehoord het eensluidend advies van eerste auditeur P. Barra;

Gelet op de artikelen 17 en 18 en titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

OVERWEEGT WAT VOLGT :

De gegevens van de zaak

1. Bij wijze van openbare aanbesteding schrijft de verwerende partij de volgende opdracht uit : “Vervangingsnieuwbouw Woon- en zorgcentrum voor ouderen Zusterhof-Campus Hadschot Gerststraat 67 2440 Geel”.
2. Met een brief van 22 januari 2008 stelt de verwerende partij de verzoekende partij, die had ingeschreven, ervan in kennis dat ze de opdracht niet kreeg toegewezen; in bijlage is het aanbestedingsverslag gevoegd. In de brief wordt vermeld dat de verzoekende partij over een termijn van 10 kalenderdagen beschikt om “eventueel in beroep te gaan”.

3. Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State mag deze enkel kennis nemen van beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden en van de wetgevende vergaderingen of van hun organen, daarbij inbegrepen de ombudsmannen ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Arbitragehof, van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges evenals van organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot overheidsopdrachten en leden van hun personeel.

Het Hof van Cassatie stelt in zijn arrest van 14 februari 1997 (nr. C.96.0211) dat instellingen, opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, in beginsel administratieve overheden zijn in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden maar dat het toevertrouwen aan een naamloze vennootschap van een taak van algemeen belang ook al is die vennootschap opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, deze haar privaatrechtelijk karakter niet doet verliezen, ingeval zij geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden.

In het arrest van 10 juni 2005 (nr. C.04.0278) heeft het Hof van Cassatie in dezelfde zin gesteld dat een vennootschap die, ook al is zij opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de overheid, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, niet de aard heeft van een administratieve overheid en het hiervoor niet terzake doet dat haar een taak van algemeen belang wordt toevertrouwd. Het Hof besliste voorts, na onderzoek van drie bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die op de sociale huisvestingsmaatschappijen betrekking hebben, dat uit die bepalingen niet kan worden afgeleid dat aan die maatschappijen een beslissingsbevoegdheid wordt verleend om beslissingen te nemen die derden binden en dat de aldaar in het geding zijnde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gewestelijke maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk aldus geen administratieve overheid is in de zin van voormeld artikel 14 van de wetten op de Raad van State.

4. De verwerende partij en de tussenkomende partij roepen een exceptie in die zich op de voormelde rechtspraak steunt om in huidig geding tot gebrek aan rechtsmacht voor de Raad van State te besluiten.

5. Uit de subsidiaire rechtsmacht van de Raad van State -als administratief rechtscollege- en uit de voormelde rechtspraak van het Hof van Cassatie mag het vermoeden worden afgeleid dat de Raad van State niet over rechtsmacht beschikt indien de verwerende partij een private rechtspersoon is aangezien deze in principe niet over de bevoegdheid beschikt om eenzijdig bindende beslissingen te nemen. Dit is dan enkel anders indien het tegenbewijs wordt geleverd en aangetoond wordt dat dergelijke beslissingsmacht wel tot de bevoegdheid van die rechtspersoon behoort en kan worden betrokken op de bestreden beslissing.

Te dezen beperkt de verzoekende partij zich ter terechtzitting tot het argument, dat de verwerende partij derden vermag te binden aangezien zij bezoekersreglementen opstelt die de toegang van bepaalde derden tot haar instelling verbiedt.

Ongeacht het feit dat de verzoekende partij niet verwijst naar enige regelgeving waarop de voormelde en niet nader verduidelijkte bevoegdheid in rechte steunt, lijkt dergelijke bevoegdheid niet als een beslissingsbevoegdheid te mogen worden aangemerkt om beslissingen te nemen die derden binden in de zin van de voormelde rechtspraak, nu ze lijkt voort te vloeien uit de prerogatieven die aan het privaatrechtelijk eigendomsrecht zijn verbonden en geen uitdrukking zijn van een eenzijdige “imperiumbevoegdheid”.

Aldus blijkt niet dat de verwerende partij, een private rechtspersoon, de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen die derden binden. Overigens kunnen de betrokken bezoekersreglementen niet worden betrokken op de bestreden beslissingen.

Aan de voormelde conclusie wordt ten slotte geen afbreuk gedaan door het feit dat te dezen de regelgeving inzake overheidsopdrachten toepasselijk zou zijn of zou zijn toegepast. Die omstandigheid zou immers niet van aard zijn om daaruit af te leiden dat de verwerende partij bij het toepassen van die regelgeving als administratieve overheid is opgetreden. Die regelgeving kan immers ook van toepassing zijn op privé-personen.

De exceptie wordt dus aanvaard. De verwerende partij heeft bij het nemen van de bestreden beslissingen niet gehandeld als administratieve overheid zoals bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Het is dienvolgens niet aan de Raad om van een beroep tot nietigverklaring van de bestreden beslissingen van de verwerende partij kennis te nemen. Het is aldus evenmin aan de Raad van State om over de vordering tot schorsing te beslissen, nu overeenkomstig artikel 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement enkel mogelijk is indien deze vatbaar zijn voor nietigverklaring, hetgeen te dezen zoals hiervoor is gebleken, niet het geval is.

**OM DIE REDENEN
BESLIST DE RAAD VAN STATE :**

Artikel 1.

Het verzoek tot tussenkomst van de NV Heijmans Bouw in het administratief kort geding wordt ingewilligd.

Artikel 2.

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

Artikel 3.

De kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bepaald op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

De kosten van de tussenkomst in de schorsingsprocedure, bepaald op 125 euro, komen ten laste van de tussenkomende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op
negentien februari 2008, door :

de H.	D. VERBIEST	kamervoorzitter,
Mevr.	T. TEMMERMAN,	griffier.

De griffier,

De voorzitter,

T. TEMMERMAN.

D. VERBIEST.